

1500855-59.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

10.) Ana Maria, guarda municipal, ouvida às fls.131, aduziu que estavam patrulhamento pelo local dos fatos chamado de "Viela da Mina" que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500855-59.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-59.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096712/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 24169090 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2096712 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JEAN ELIAS APOSTOLO MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de JEAN ELIAS APOSTO MOREIRA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 07 de abril de 2022, às 23h:45min, na Rua Soldado Paulo Sérgio Romão, nº 147 - Viela da Mina 165, Parque Santana, Santana de Parnaíba-SP, o réu, tinha em depósito e guardava, para fins de mercancia ilícita, 68 (sessenta e oito) frascos contendo 680 mililitros da substância cloreto de metano/diclorometano, popularmente conhecida como "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 5.405,00 (cinco mil quatrocentos e cinco reais).

1.1.) Segundo a peça acusatória, Guardas Municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um indivíduo pela via, posteriormente identificado como JEAN ELIAS APOSTOLO MOREIRA, que aparentou nervosismo e correu.

1.2.) A Guarnição conseguiu alcançar o denunciado e, em revista pessoal, foi localizado no bolso de sua calça o valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em dinheiro.

1.3.) Ao ser indagado sobre o valor encontrado, JEAN ELIAS alegou ser gerente do tráfico de drogas no bairro, bem como informou sobre a existência de frascos de lança-perfume em sua residência.

1.4.) Os Guardas Municipais se dirigiram juntamente com o denunciado até a sua casa, oportunidade em que JEAN ELIAS entrou no local e, após alguns instantes, retornou trazendo um saco que continha 68 frascos de lança-perfume, bem como a quantia de R\$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais) proveniente da venda das drogas.

1.5.) Ouvido, o denunciado confessou que guardava os frascos de lança-perfume em sua residência para fins de mercancia ilícita.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.28/30), o auto de exibição e apreensão (fls.14/15) e o laudo de constatação (fls.25/27).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.120/122, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano).

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.76/79), mas, a decisão de fls.94/96 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls.130/131).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo ter sido abordado anteriormente pelos guardas, os quais procuravam o "magnata" (dono da biqueira), desconhecido pelo réu. Na data dos fatos, estava no local para comprar maconha para uso próprio, quando foi abordado novamente logo após sair do serviço. Ainda, relatou que os policiais o ameaçaram dizendo que se ele não delatasse o "magnata" eles iriam forjar o flagrante contra ele. Em seguida, se dirigiram até sua residência, onde encontraram os lança-perfumes, que ele venderia para seus colegas no baile, e R\$ 8.000,00 que ele guardava para comprar uma motocicleta (fls.128).

5.) Vieram alegações finais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Defendeu o afastamento do tráfico privilegiado, devendo ser fixado o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade (fls.132/135).

5.1.) O réu, por seu turno, sustentou, preliminarmente, a nulidade do ingresso em sua residência e da prisão efetuada por guardas municipais. No mérito, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pela atenuação da pena pela confissão e menoridade relativa e aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.
Fundamento.

6.) As preliminares se confundem com o mérito e, neste, a ação é procedente.

7.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu, tinha em depósito e guardava, para fins de mercancia ilícita, 68 (sessenta e oito) frascos contendo 680 mililitros da substância cloreto de metano/diclorometano, popularmente conhecida como "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 5.405,00 (cinco mil quatrocentos e cinco reais).

8.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fls.14/15), pelo laudo de constatação (fls.25/27), bem como pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano - fls.120/122), a par da prova oral produzida.

9.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

10.) Ana Maria, guarda municipal, ouvida às fls.131, aduziu que estavam patrulhamento pelo local dos fatos chamado de "Viela da Mina" que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o réu que empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição. Em seguida, o réu foi alcançado e, ao ser indagado, confessou informalmente que era gerente do tráfico no local e que tentou fugir por medo e que o dinheiro que estava em sua calça era oriundo da venda de entorpecentes. Ato contínuo, o réu aduziu que na sua residência, próxima ao local dos fatos, ele guardava entorpecentes, vindo a levar os guardas até o local. No interior do imóvel, o réu pegou uma toca com R\$ 5.075,00 e uma sacola preta com os frascos de lança-perfume. Ainda, acrescentou desconhecer o réu. Nesta toada, temos o depoimento de Ezequiel, também guarda municipal, ouvido às fls.130, tendo este acrescentado que na residência do réu foram localizados 68 frascos com lança-perfume.

10.1.) São inaceitáveis as preconceituosas teses de que os guardas municipais não podem efetuar a prisão em flagrante e a de que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

Ainda, como qualquer do povo, os guardas civis poderão e deverão prender quem quer seja encontrado em flagrante delito e apreender os bens produtos de ilícito em tais circunstância, em função do quanto disposto no artigo do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Também, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social.

Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 290.371/SP Relator Ministro MOURA RIBEIROj. 27.05.14; RHC 45.173/SP Relator Ministro JORGE MUSSI j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Relator Ministro ARNALDOESTEVES LIMA j. 23.02.10)"

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib;
Data de Registro: 29/04/2022)

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

12.1.) O réu foi surpreendido tendo em depósito 68 frascos com “lança-perfume”, além da quantia de R\$ 5.405,00 em espécie, a qual não obteve sucesso em comprovar que era oriunda de seu labor na construção civil, circunstâncias que demonstram de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

12.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

12.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita, permanecendo isolada a afirmação de que trabalharia como cabelereiro.

12.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

13.) Inexistindo discriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu JEAN ELIAS APOSTOLO MOREIRA como incurso no Art. 33, caput e § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes dos Arts. 59 e 68, do Código Penal e do Art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual entendo regular ao tipo penal.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nada a considerar.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, o réu não comprovou ocupação lícita na construção civil, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, JEAN, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio, mentindo em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar os guardas municipais responsáveis por sua prisão, aduzindo que os agentes da lei teriam forjado o flagrante por ela não ter delatado o "magnata", vindo a invadir sua residência e a subtrair mais de R\$ 2.000,00 de suas economias, o que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019).

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obtemperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do

permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaca que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, retornando-a ao mínimo legal.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu JEAN ELIAS APOSTOLO MOREIRA em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

20.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

21.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA